

1500260-46.2021.8.26.0655

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Érica Midori Sanada

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380. "Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492).

APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO- Pretensão de absolvição por falta de provas ou desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06
Impossibilidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

1ª Vara

Avenida Fernão Dias Paes Leme, 2323 / 2329, Varzea Paulista - SP - cep 13220-005

1500260-46.2021.8.26.0655 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500260-46.2021.8.26.0655

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Midori Sanada

Vistos.

MARCELO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, já devidamente qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e artigo 244-B da Lei n.º 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 22 de abril de 2021, no período da manhã, na Rua Araré, n.º 50, Parque Guarani, nesta cidade e Comarca de Várzea Paulista, agindo em concurso e unidade de propósitos, com divisão de tarefas, com os adolescentes A.L.L.R e G.A.P.K., teriam trazido com eles 16 (dezesesseis) porções de Skunk, 35 (trinta e cinco) porções de maconha; 29 (vinte e nove) porções de cocaína; e 09 (nove) porções de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros (cf. auto de exibição e apreensão às fls. 09/10, laudo de constatação de fls. 34/37 e laudo de exame toxicológico definitivo a ser oportunamente juntado).

O réu foi pessoalmente notificado (pág. 92/93) e apresentou defesa (pág. 85/87).

Na defesa prévia, aduziu a Defesa que o réu é inocente, tendo em vista que os

entorpecentes foram encontrados na posse dos adolescentes e não com ele. Afirmou que ele estava no local apenas para comprar entorpecentes, eis que é apenas usuário. Ao final, pugnou por sua absolvição.

A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2021 (pág. 97/98).

A seguir o réu foi citado (pág. 118/119).

Em audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas e, por fim, foi o réu interrogado.

Em debates orais finais, pugnou o(a) representante do Ministério Público pela procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da denúncia. Em seguida a Defesa pugnou pela improcedência da ação, alegando fragilidade probatória.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Da Materialidade:

A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (pág. 01), pelo boletim de ocorrência (pág. 02/05), pelo auto de exibição e apreensão (pág. 09/10), pelo laudo de constatação provisória (pág. 34/37), pela folha com anotações do tráfico (pág. 46/47), pelo exame químico toxicológico definitivo (pág. 80/82), com resultado positivo para MACONHA e COCAÍNA, bem como pelos depoimentos prestados na fase policial e em juízo.

Das Provas Colhidas:

Na fase policial o réu MARCELO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, assim relatou:

"Que é usuário de drogas e que estava indo comprar droga. E que Adrian e Gabriel que estavam vendendo os entorpecentes". Que no dia dos fatos foi até o local para adquirir maconha, para uso próprio, momento em que foi abordado pelos Guardas Municipais. Que foi levado até a delegacia, sendo posteriormente dispensado. Que faz uso de entorpecentes desde os 16 anos. Que possuía consigo o importe de R\$ 116,00. Que fazia alguns bicos. Que conhecia os adolescentes de vista. Que já conhecia os guardas municipais que lhe prenderam, pois sempre diligenciavam pelo local dos fatos.

Por sua vez, o guarda municipal, JEFFERSON LAZARO MATOS, assim esclareceu na fase policial:

"Que em patrulhamento pelo local dos fatos, ao avistar a viatura da Guarda Municipal os três indivíduos fugiram correndo. E logo após perseguição a pé, foi possível capturá-los e identificá-los. No local Adrian Leonardo e Gabriel Aparecido estavam em posse dos entorpecentes apreendidos e Marcelo Augusto estava com o dinheiro apreendido - em diversas notas de R\$ 2,00, R\$ 5,00 e demais notas, além de diversas moedas - totalizando R\$ 112,00. Todos foram conduzidos para esta Distrital e as substâncias apreendidas". O que foi ratificado em juízo. Que o réu estava portando dinheiro. Que o réu não estava com as drogas. Que haviam outras pessoas no local.

Dando continuidade, o guarda municipal MARCEL JACINTO LOPES, assim relatou na fase policial:

"Que em operação ao combate de tráfico de drogas na região e com o auxílio da Polícia Civil, em patrulhamento pelo local dos fatos, ao avistarem as viaturas os três indivíduos fugiram correndo. E logo após perseguição a pé, foi possível

capturá-los e identificá-los. No local Adrian Leonardo e Gabriel Aparecido estavam em posse dos entorpecentes apreendidos e Marcelo Augusto estava com o dinheiro apreendido - em diversas notas de R\$ 2,00, R\$ 5,00 e demais notas, além de diversas moedas - totalizando R\$ 112,00. Todos foram conduzidos para esta Distrital e as substâncias apreendidas". O que foi ratificado em juízo. Que o réu alegou que estava trabalhando no tráfico de drogas. Que os indivíduos réus estavam juntos. Que já conhecia o réu antes dos fatos, pois o mesmo sempre estava próximo ao ponto de tráfico. Que o réu não estava na posse de entorpecentes. Que próximo ao local haviam outros usuários.

Por fim, o policial civil DIRCEU DA SILVA ALMEIDA, assim relatou na fase policial:

"Que estava em apoio aos guardas municipais em operação de combate ao tráfico de entorpecentes quando os guardas tentaram abordar três indivíduos que fugiram correndo e foram presos logo mais a frente e constatado que portavam drogas e dinheiro. Que auxiliou na condução até esta delegacia e apresentou à autoridade policial". O que foi ratificado em juízo. Que não se recorda se o réu falou algo no momento da prisão. Que não viu o momento da prisão. Que já conhecia o réu antes dos fatos, em outras diligências.

Do Valor e do Conjunto da Prova:

Dos Depoimentos dos Agentes de Segurança Pública:

É importante salientar que a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos.

Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para depois, quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade.

Anoto que pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para afastar tal prova.

Consigno que o próprio Colendo Supremo Tribunal Federal deixou assentado:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Face as provas colhidas nos autos, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava dividida, bem como, os depoimentos seguros prestados pelos agentes, levam à certeza de que o réu traficava drogas na ocasião, impondo-se, pois, a sua condenação.

Nessa linha:

"Apelação - Justiça Pública - Tráfico de Drogas - Condenação - Necessidade - Materialidade e autoria comprovadas - Apreensão de 20 pedras de crack - Depoimentos seguros e harmônicos dos policiais responsáveis pelo flagrante - Suficientes elementos para embasar a condenação - Pena - Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal - Incidência da circunstância agravante da reincidência - Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas por ausência de preenchimento dos requisitos - Imposição de Regime Fechado. Recurso de Apelação provido para condenar o réu André da Silva Ferreira à pena de 05 anos e 10

meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a 583 dias multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343, de 2006, fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena, expedindo-se mandado de prisão em desfavor do réu, após o trânsito em julgado." (Apelação nº 0006970-48.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas. 4ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator: César Augusto Andrade de Castro. Julgado em 29/04/2015).

Do Pedido de Desclassificação do Delito:

Diante o conjunto probatório dos autos, demonstrando-se claramente a traficância, não se autoriza a pretendida desclassificação da conduta como simples consumo pessoal (artigo 28, da Lei nº 11.343/06).

Anoto que nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, e face as demais provas colhidas nos autos, competia ao requerido comprovar que seria apenas usuário de entorpecente, o que não foi feito.

Neste sentido:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380. "Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492).

APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO- Pretensão de absolvição por falta de provas ou desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06
Impossibilidade - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas nos autos - Versão do réu restou incomprovada - Palavras dos policiais civis - Não haveria como se questionar tais depoimentos, eis que se revestem de fé-pública e foram corroborados pelas demais provas Traficância - Condenação era de rigor - Penas e regime inicial fechado corretamente aplicados- Impossibilidade de substituição das penas corpóreas por restritivas de direitos - Recurso defensivo desprovido. (Apelação nº 3009705-74.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo. 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator: Edison Brandão. Julgado em 12/05/2015).

EMENTA: Apelação criminal Tráfico ilícito de entorpecente - Sentença condenatória - Apelo do réu objetivando a absolvição ou a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos. Razoável quantidade de cocaína apreendida, além de grande quantia em dinheiro trocado. Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Penas e regime prisional corretamente fixados - Gravidade concreta da conduta do apelante que revela a sua elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a manutenção do regime eleito, servindo, de resto, como obstáculo à substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Recurso improvido. (APELAÇÃO Nº 0002426-75.2011.8.26.0397. Comarca de Nuporanga. 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator: Moreira da Silva. Julgado em 12/02/2015).

Do Crime de Tráfico:

O crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que a simples conduta do réu, agindo em concurso e unidade de propósitos, com divisão de tarefas com os adolescentes, consistente em "trazer consigo" a

substância entorpecente, já é suficiente para caracterização do delito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

No caso em tela, relataram os agentes de segurança pública (policial civil e guardas municipais), que realizavam operação para o combate do tráfico de entorpecentes, quando no local visualizaram três indivíduos (dois adolescentes e o réu), os quais saíram correndo, quando perceberam a aproximação da viatura. Na sequência foram acompanhados e abordados.

Com os adolescentes os agentes encontraram 16 porções de maconha do tipo Skunk, 35 porções de maconha, 29 porções de cocaína e 09 porções de crack, e com o réu encontraram R\$ 112,00 em dinheiro, em notas trocadas (pág. 67), conforme auto de exibição e apreensão (pág. 09/10).

Além disso, foi encontrada a anotação de contabilidade às pag. 46/47, no exato montante encontrado com o requerido.

Na fase policial, o réu negou os fatos, dizendo que estava no local apenas para comprar entorpecente, eis que é usuário de drogas e que os adolescentes seriam os traficantes.

Entretanto, restou evidente que o réu e os adolescentes estavam agindo em concurso de agentes, na mercancia dos entorpecentes. Sendo que os adolescentes ficavam com as drogas, enquanto o réu era o responsável pelo recebimento do dinheiro. Com o réu os agentes encontraram R\$ 112,00 em notas pequenas trocadas, quantia esta, repito, alinhada no documento de pag. 46/47. Ademais, não demonstrou o réu a origem lícita de tal quantia.

É ainda de se observar, que o réu foi preso em decorrência destes autos no dia 22/04/2021 e logo na sequência foi beneficiado com a liberdade. Atualmente, está preso por suposta prática de traficância, no dia 30/12/2021 (2ª Vara Judicial desta Comarca de Várzea Paulista, processo n.º 1503325-91.2021.8.26.0544).

Vale ainda, salientar, que não há motivos para se duvidar das palavras dos agentes de segurança, que nem ao menos conheciam o réu, e não teriam qualquer motivo para incriminá-lo. Portanto, cabia ao réu provar sua versão, fato do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

É ainda de se observar, que o artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006 traz dezoito núcleos para a caracterização do tipo penal, e qualquer deles é mais do que o suficiente para a caracterização do delito.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Diante do exposto, a condenação do réu é medida que se impõe, nos termos do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Do artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006:

O réu foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06 e artigo 244-B da Lei n.º 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 22 de abril de 2021, no período da manhã, na Rua Araré, n.º 50, Parque Guarani, nesta cidade e Comarca de Várzea Paulista, agindo em concurso e unidade de propósitos, com divisão de tarefas, com os adolescentes A.L.L.R e G.A.P.K., teriam trazido com eles 16 (dezesseis) porções de Skunk, 35 (trinta e cinco) porções de maconha; 29 (vinte e nove) porções de cocaína; e 09 (nove) porções de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros (cf. auto de exibição e apreensão às fls. 09/10, laudo de constatação de fls. 34/37 e laudo de exame toxicológico definitivo a ser oportunamente juntado).

Entretanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a questão deve ser resolvida pelo princípio da especialidade. Assim, se forem praticados os crimes dos artigos 33 a 37, da Lei n.º 11.343/2006, conjuntamente com menor, incidirá apenas a majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006. Nos demais delitos, ocorrerá o crime autônomo do artigo 244-B do ECA.

Segundo o STJ, na hipótese de o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não estar previsto nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos (33 a 37), não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido:

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR: O debate consistiu no enquadramento da conduta de adulto que pratica tráfico em concurso eventual com criança ou adolescente. Para configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), basta a participação de menor de 18 anos no cometimento do delito, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, o crime é formal e, por isso, independe da prova da efetiva corrupção do menor (Súmula n. 500/STJ). Por sua vez, para incidir a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, faz-se necessário que, ao praticar os delitos previstos nos arts. 33 a 37, o réu envolva ou vise atingir criança, adolescente ou quem tenha capacidade de entendimento e determinação diminuída. Não se compartilha do entendimento no sentido de que, se a criança ou adolescente já estiverem corrompidos, não há falar em corrupção de menores e de que responde o agente apenas pelo crime de tráfico majorado, pois, de acordo com o entendimento do STJ, é irrelevante a prova da efetiva corrupção do menor para que o acusado seja condenado pelo crime do ECA. A solução deve ser encontrada no princípio da especialidade. Assim, se a hipótese versar sobre concurso de agentes envolvendo menor de dezoito anos com a prática de qualquer dos crimes tipificados nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, afigura-se juridicamente correta a imputação do delito em questão, com a causa de aumento do art. 40, VI. Para os demais casos, aplica-se o art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme entendimento doutrinário. (Informativo n. 595) (REsp 1.622.781-MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, julgado em 22/11/2016, DJe 12/12/2016").

No caso em tela, de acordo com a prova colhida nos autos, o crime de tráfico envolveu dois adolescentes, causando desequilíbrio social e desarmonia, razão pela qual a pena deve ser aumentada nos termos do artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006.

Restou devidamente comprovado nos autos, que o réu cometeu o delito de tráfico de entorpecentes, agindo em concurso e unidade de propósitos, com divisão de tarefas, com os adolescentes A.L.L.R e G.A.P.K., para que juntos tivessem êxito na empreitada criminosa.

Neste sentido, destaco o que já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Relator Airton Vieira, Apelação 0002956-86.2013.8.26.0081, j. 26/11/2015, in site TJSP:

"Ementa: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06. PENA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE "BIS IN IDEM" ENTRE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AFASTADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉUS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o Juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Precedentes do STF. 2. A materialidade e as autorias do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse de adolescente que a transportava para os réus. 3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10). 4. Incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista o evidente envolvimento de menor com os réus na prática do crime de tráfico de drogas, o que devidamente comprovado pela prova oral judicial. 5. Penas reformadas. 6. Havendo condenações diversas, mediante sentenças transitadas em julgado, inexiste violação ao princípio do "non bis in idem", se uma ou mais delas são tomadas para os fins de reconhecimento de maus antecedentes criminais, na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59, "caput", do Código Penal) e outra ou outras diferentes são tomadas para os fins do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena (art. 61, I, do Código Penal). Inteligência, ademais, da Súmula 241, do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a Doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini, Guilherme

de Souza Nucci, André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves. Assim a jurisprudência do STF (RHC 92.611/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.05.13; RHC 110.727/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 21.05.10 e HC 94.846/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.10.08). E a do STJ (HC 271.901/SP, Rel. Min. Ericson Marinho, Desembargador convocado do TJSP, j. 24.03.15; HC 210.359/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 03.03.15; HC 213.481/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.11.14; HC 266.828/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 18.06.14; HC 268.859/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, DJe 23.04.14; HC 267.543/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.05.13; HC 203.898/MS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.04.12; HC 145.061/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 28.09.10). 7. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primordialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF. 8. Regime inicial de cumprimento de pena para os crimes hediondos será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. Ainda mais porque as penas definitivas foram fixadas acima de oito anos e também porque as penas-base foram exasperadas. 9. Provimento parcial dos recursos defensivos."

Passo a Dosar a Pena:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 42, da Lei 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, constato que o réu é tecnicamente primário (pág. 114/115). As demais circunstâncias judiciais são punidas pela própria tipicidade do delito, motivo pelo qual fixo a pena base no mínimo legal, qual seja: 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo a atenuante da MENORIDADE, no entanto, estando a pena no mínimo legal, não é caso de diminuição da pena.

Na terceira fase de aplicação da pena, considerando que o delito envolveu os adolescentes A.L.L.R e G.A.P.K., a pena deverá ser aumentada em 1/6, de acordo com o previsto no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, resultando na pena de: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ainda na terceira fase de aplicação da pena, entendo não ser o caso de aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o réu, agindo em concurso com os adolescentes, foram detidos com: 16 porções de maconha do tipo Skunk, 35 porções de maconha, 29 porções de cocaína e 09 porções de crack, conforme auto de exibição e apreensão (pág. 09/10). Se desse modo ele conseguia o seu sustento (com a venda dos entorpecentes), certo que o "crack" e a "cocaína" é tipo de substância entorpecente que reclama, para a sua produção, a posse de um laboratório especializado, o que não consta ser possuído pelo réu, levando à conclusão de que ele conseguia os entorpecentes com terceiros, demonstrando o envolvimento com organização criminosa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes e condutas afins Recurso da defesa Requerimento de reforma parcial da r. sentença de primeiro grau, notadamente no que tange à dosimetria da reprimenda Requerimento de aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei Antidrogas Inviabilidade Benefício que não comporta concessão e virtude do não preenchimento de todos os requisitos legais Programa prisional que

não comporta abrandamento, vedada a substituição da reprimenda corporal ante a existência de óbice legal. Adequada aplicação da pena de multa, de modo que a hipossuficiência financeira não é critério para sua modificação. Apelo improvido. Recurso do Ministério Público Pedido de imposição do regime prisional inicial fechado Cabimento Necessário a adequação do regime prisional imposto, já que evidenciada a dedicação do réu à atividade criminosa, inaplicável a eleição do programa prisional intermediário Recurso defensivo improvido e recurso ministerial Provido. (Apelação n.º 0001172-76.2017.8.26.0617 – 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator: Sérgio Ribas – Julgamento 16/05/2019).

Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a “quantidade ou a qualidade” das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é “primário”, “de bons antecedentes”, “não integre organização criminosa” e “não está envolvido com atividades criminosas” (§ 4º, segunda parte, do art. 33 da Lei 11.343/06). Nesta ação penal, com clareza solar, o réu “está envolvido com atividades criminosas” porque trazia consigo e tinha em depósito e guardava, em local conhecido como ponto de venda de drogas, sendo elas variadas, em quantidade expressiva e, ainda, envolvendo a participação de adolescente e, isto, por si só, demonstra circunstâncias concretas que, no mínimo, levam à conclusão de que, com habitualidade, recebe os entorpecentes (mediante compra ou consignação) do grande traficante para, na sequência, comercializa-los no varejo em porções. Afinal, ‘ponto de tráfico’ significa ‘ponto de comércio ilícito’ que entre suas medulares características estão o ‘meio de vida à margem da legalidade’, a ‘organização e prevenção contra a atuação das autoridades de polícia’, a ‘disputa clandestina do sítio utilizado na atividade’ e a ‘freguesia viciada’. Ademais, não se olvide que a benesse tem natureza excepcional e não regra geral e assim deve ser tratada, sob pena de indevido esvaziamento das sanções em abstrato cominadas para o delito de tráfico de entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado ahediondo(STF HCnº122594/SP PrimeiraTurma Rel. MinistraRosaWeber J.23.09.2014 Dje07.10.2014; STJ-Agrgno AREsp 359220/MG Sexta Turma Rel. Maria Thereza de Assis Moura J. 03.09.2013 Dje 17.09.2013; TJSP Apelação nº 0027092-46.2013.8.26.0050 15ª Câmara de Direito Criminal Relator J. Martins J. 08.05.2014).

Nesse sentido, segue transcrição do trecho do relatório elaborado no Recurso de Apelação n.º 0000997-86.2017.8.26.0066, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que foi Relator TOLOZA NETO, da 3ª Câmara de Direito Criminal, publicado no DJe em 23 de janeiro de 2018:

“(***). No mais, não faz jus a apelante, ainda, à concessão da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Para a sua aplicação, é indispensável que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Não resta dúvida, assim, de que tal causa de diminuição de pena é de ser aplicada apenas àquele que tenha praticado o delito de maneira isolada, como um pequeno deslize em sua vida, ainda que penalmente punível. Aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de vida, mesmo que não tragam em sua folha de antecedentes condenações por outros crimes, não fazem jus ao benefício. A causa de redução deve ser aplicada em caráter excepcional, em situações específicas, quando não houver dúvidas de que o réu veio a cometer o ato como um desvio em sua vida, e não de modo contumaz e habitual. No caso dos autos, ficou demonstrado que o apelante não pode, de forma alguma, ser considerado como traficante ocasional, pois possui condenação recente pela prática do mesmo delito dos autos (fls. 174/175), além de ostentar passagens anteriores enquanto menor de idade, o que permite a assertiva de que se dedica à atividade criminosa. Além disso, o apelante Wilkesler foi detido em poder de inúmeras porções de cocaína e uma balança digital de precisão. Por óbvio, não haveria razão ou condição econômica para possuir tal quantidade de entorpecente. Evidente que vivia do exercício da traficância, tendo declarado estar desempregado (***).”.

Ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena, esta pena torna-se definitiva.

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena:

O tráfico de entorpecentes é crime gravíssimo, pois a intenção do traficante é levar ao vício o maior número possível de vítimas. Além disso, cuida-se de delito equiparado a hediondo, razão pela qual o réu deverá cumprir sua pena em regime inicialmente FECHADO, como expressamente previsto no artigo 2º, inciso II, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07.

Outrossim, as circunstâncias do caso em tela revelam, mormente pela natureza lesiva e potencialmente letal das substâncias entorpecentes encontradas, "maconha", "crack" e "cocaína", se desse modo que ele conseguia o seu sustento, certo que o "crack" e a "cocaína" é tipo de substância entorpecente que reclama, para a sua produção, a posse de um laboratório especializado, o que não consta ser possuído pelo réu, razão que se impõe, mesmo, o regime prisional mais gravoso. Não bastasse, a forma de acondicionamento das drogas apreendidas e as circunstâncias da abordagem do réu estão a impor, ainda com maior razão, o regime prisional fechado, não se perdendo de vista a correlação entre o artigo 59, "caput" e o artigo 33, § 3º, ambos do Código Penal.

Não se faz presente a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, porque tais benefícios são incompatíveis com a finalidade da Lei nº 8.072/90, que dá tratamento mais rigoroso aos chamados crimes hediondos e assemelhados e que prevê, dentre outras hipóteses, a fixação de regime inicial fechado para cumprimento da sanção imposta ao protagonista de delitos deste jaez.

Acerca da constitucionalidade da vedação à conversão da pena privativa de liberdade em sanção alternativa, nesse sentido, aliás, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, ponderando que embora tenha o Supremo Tribunal Federal afirmado ser inconstitucional a proibição de conversão de penas em crime de tráfico (HC 97.256, rel. Min. Ayres Brito), deve ser ressalvado que tal decisão foi adotada em sede difusa, por maioria de votos e sem efeito vinculante (cf. HC 168.459/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 21/10/10).

Por fim, ressalto que o delito em questão, é de especial gravidade, consistindo em causa ou consequência da prática de outros crimes tão ou mais graves e intimamente ligados com a criminalidade violenta e com a desestruturação de inúmeras famílias.

Da Pena Pecuniária:

O valor do dia-multa deve ser calculado nos termos do artigo 43, da Lei nº 11.343/06, sendo fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos que pudesse majorar tal pena.

Não há que se falar na não aplicação da pena de multa, sob a alegação de que o réu é beneficiário da justiça gratuita, eis que a pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal e fora estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e ainda no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de quantidade razoável de crack - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida; Tráfico de

entorpecentes – Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminoso – Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Inaplicabilidade – Multa – Pena prevista no preceito secundário do tipo de tráfico de entorpecentes e estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício – Recurso improvido (Apelação Criminal n.º 0001590-39.2017.8.26.0544 – da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo –Relator: Alexandre Almeida – Julgamento: 08/04/2021).

Do Dispositivo:

Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, que o Ministério Público move em face de MARCELO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, já devidamente qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente FECHADO, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Da Prisão Preventiva:

Dada a necessidade de resguardo da ordem pública, assim como, para garantia de aplicação da lei penal, decreto a prisão do requerido. EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO.

Vale aqui consignar, que o réu foi preso em decorrência destes autos no dia 22/04/2021 e logo na sequência foi beneficiado com a liberdade, entretanto, no dia 30/12/2021, novamente veio a ser preso e está respondendo pelo delito de tráfico de entorpecentes, perante a 2ª Vara Judicial desta Comarca de Várzea Paulista, processo n.º 1503325-91.2021.8.26.0544, pelo qual está preso, conforme certidão de objeto e pé (pág. 114/115).

Frise-se que é imperiosa a decretação da custódia do réu, com o fim de garantir a aplicação da lei penal e preservar a coletividade contra pessoas potencialmente perigosas.

Quem enverada para prática desses tipos de criminalidade, indisfarçavelmente tem personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública.

A doutrina afirma que:

“As causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do assecuramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, editora RT, 9ª edição, p.635).

Dos Efeitos da Condenação:

Custas na forma da lei.

Autorizo a incineração da substância entorpecente apreendida. Se o caso, oficie-se.

Comprovada a traficância e o fato da importância encontrada com o réu ser proveniente/destinado ao tráfico, declaro a perda da mesma (pág. 09/10 e 67) em favor da União nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Paulista, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Certifico que, na data inserida no sistema informatizado, foi publicada em cartório a r. Sentença. O escr.